

1501453-80.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... "caput", da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte da ré, na medida em que, juntamente com outros indivíduos, guardava e tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, tanto em solo policial quanto em juízo a acusada Ana Paula confessou que trabalhava para o tráfico de drogas, realizando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501453-80.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501453-80.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201193/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 19248369 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2531/21/406 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2201193 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IZABELLA CAROLINA DA SILVA XAVIER e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

IZABELLA CAROLINA DA SILVA XAVIER, PABLO DA SILVA BARBOSA, ANA PAULA DE SOUZA, DANILO ALMEIDA DA SILVA e MIRIAM DA SILVA FERNANDES LUCENA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 182/184).

Oferecida a denúncia (fls. 184/188), esta foi recebida (fls. 189/191) e os requeridos citados.

Após a apresentação de defesas escritas pelos réus Pablo, Izabella, Ana Paula (fls. 329/330, 341/349 e 362/367, respectivamente) o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 375).

O processo foi desmembrado em relação aos réus DANILO ALMEIDA DA SILVA, PABLO DA SILVA BARBOSA e MIRIAM DA SILVA FERNANDES LUCENA (fls. 375).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e interrogados os acusados.

Encerrada a instrução criminal, manifestou-se o Ministério Público em alegações finais orais, requerendo a parcial procedência do feito, ao passo que as defesas técnicas apresentaram memoriais escritos (fls. 404/405, 406/417 e 418/428), nos mais pugnaram pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar de nulidade da prova será analisada conjuntamente ao mérito.

Não há outas preliminares a serem apreciada.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, apenas restou comprovado nos autos que a acusada Ana Paula praticou o delito.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, em relação à ré Ana Paula, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), pelos laudos químico toxicológico (fls. 169/171, 257/259 e 260/262), que atestam pelo resultado positivo para maconha e cocaína, pelo relatório final (fls. 173/175), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Policiais André Dantas Lima, quando inquirido em juízo, disse que receberam denúncia dando conta de que uma casa situada em determinada viela servia de local de guarda de entorpecentes, vulgarmente conhecida como "casa bomba".

Asseverou que a viela descrita na delação é conhecido ponto de venda de drogas, sendo que, quando atuou em outra unidade policial, realizaram diversas prisões no recinto.

Informou que, respeitante ao imóvel, foram recebidos pela ré Miriam, que franqueou o ingresso no local, onde se encontrava os réus Pablo, Danilo e Izabella.

Declarou que Miriam alegou que o imóvel pertencia ao réu Lucas, o qual havia saído do recinto.

Em buscas no local, encontraram dentro de um armário uma mochila que continha a droga apreendida e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas.

Pontuou que, quando saíram do imóvel, avistaram dois veículos, sobre os quais obtiveram informações de que era utilizados pelos réus Danilo e Pablo.

Explanou que os réus confessaram a traficância informalmente, esclarecendo que praticavam o ato em algumas oportunidades.

Aduziu que, enquanto saíam do imóvel, se depararam com a ré Ana Paula, a qual apresentou grande nervosismo.

Levantaram informações de que Ana Paula integrava o grupo criminoso. Contudo, na ocasião não encontraram nada que a pudesse incriminar, motivo pelo qual ela foi conduzida como testemunha.

E a fala do policial, contra quem nada se levantou, foi harmônica e isenta de contradição relevantes, se cotejadas com os depoimentos prestados em juízo e na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade” (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais” TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

O réu PABLO, quando interrogado em juízo, disse que dormiu na residência de uma pessoa que conheceu porque mora longe. Estavam bebendo em uma adega e pernотaram no local. É apenas usuário de drogas.

Quanto ao fato de que a ré Miriam disse em solo policial que ele trabalha no

tráfico com os outros acusados, PABLO negou, informando que não trabalhava para. Apenas os conhece de vista

A ré IZABELLA, ao ser interrogada, disse que sábado estava em uma festa, onde ingeriu bebida alcoólica e fez o uso de drogas. Começou a passar mal, motivo pelo qual Miriam franqueou que pernoitasse no imóvel. No dia seguinte, domingo, tornaram a usar entorpecentes e, novamente, dormiu no local. A abordagem policial ocorreu na segunda-feira.

Pontuou que conheceu os demais réus na festa.

E a ré ANA PAULA, quando interrogada em juízo, disse que fazia campana no local dos fatos porque possuía uma dívida. É usuária e foi a primeira vez que praticou o ato. Não conhece os réus. Negou que tenha informado em solo policial que anunciava a chegada dos policiais por "whatsapp".

Pois bem.

A alegação de nulidade da prova não procede pois o "tráfico de drogas é crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo", de modo que, a teor do quanto disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal, "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

Assim, nada há de ilegal na abordagem realizada pelos agentes, sobremaneira ao se considerar que haviam denúncias dando conta da traficância que era realizada no local dos fatos e porque os policiais realizaram breve campana antes da abordagem, circunstâncias que inegavelmente legitimam a empreitada policial.

Somado a isso, depreende-se que a ré Miriam firmou documento em solo policial autorizando o ingresso dos agentes no domicílio, o que reforça, ainda mais, a legalidade da conduta dos policiais.

Prossigo.

Respeitante aos réus PABLO e IZABELLA, conforme pontuado pelo Ministério Público, não há provas inequívocas de que efetivamente estavam traficando drogas, sendo que o alibi por eles apresentados, somado aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e ao depoimento do policial inquirido em juízo, geram dúvidas acerca da autoria delitiva.

Com efeito, o direito penal, por se tratar de ultima ratio, opera com punições severas às condutas que violam os bens juridicamente tutelados, podendo culminar na restrição de liberdade do indivíduo violador da norma.

Assim, diante do seu caráter eminentemente protetivo/punitivo, a intervenção estatal, por meio da repressão penal, somente ocorrerá após o devido processo legal e desde que o estado, representado Poder Judiciário, por meio Magistrado, verificar a prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva.

Diferentemente do que ocorre na fase pré-processual, em que se prestigia o princípio in dubio pro societate, na fase endoprocessual o édito condenatório somente poderá ser proferido quando verificada a certeza do cometimento da infração penal.

E isso se dá porque, embora se pretenda a proteção do bem juridicamente tutelado, o direito penal também é instrumento para proteção do indivíduo/réu contra o Estado, resguardando-se, acima de qualquer outro direito, a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (Constituição Federal,

artigo 1º, inciso III).

Dessa forma, “na dúvida, de rigor o non liquet, ainda que, com isso, esteja-se correndo risco de brindar com imerecida absolvição aquele que fazia por merecer condenação, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reo”.

Assim, os acusados PABLO e IZABELLA devem ser absolvidos.

Por outro lado, respeitante à acusada ANA PAULA, a imputação Ministerial é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que a ré, de fato, estava a praticar a traficância.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte da ré, na medida em que, juntamente com outros indivíduos, guardava e tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, tanto em solo policial quanto em juízo a acusada Ana Paula confessou que trabalhava para o tráfico de drogas, realizando “campana”, bem como esclarecendo que é usuária e que realizava o ato para pagar dívida.

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito como tráfico de entorpecentes, sendo sua condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência:

a) absolvo IZABELLA CAROLINA DA SILVA XAVIER e PABLO DA SILVA BARBOSA, qualificados nos autos, e o faço com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal e

b) condeno ANA PAULA DE SOUZA, qualificada nos autos, como incurso artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase não há circunstâncias a serem sopesadas.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), motivo pelo qual reduzo a pena da acusada em 1/6, anotando-se, contudo, o teor da Súmula 231 do STJ, no sentido de que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

E, na terceira fase, verifico que a ré não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois esta regra não incide ao caso concreto.

Isso porque, malgrado a ré tenha afirmado em juízo que foi a primeira oportunidade em que praticou o ato, as circunstâncias em que a empreitada criminoso se desenvolveu, o fato de a ré ter praticado o crime em concurso com outros agentes e

porque ela disse em solo policial que já tinha servido ao tráfico em outras oportunidades, depreende-se que a requerida tem se dedicado à atividade criminosa.

Ademais, a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos demonstram que o tráfico de drogas é realizado no recinto de forma organizada e há muito tempo, de sorte que "o delito cometido se afigura como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não há, ainda, "livre concorrência" ou "empreendedorismo" no tráfico. Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles, ou não tivesse com eles algum vínculo".

Tais fatos demonstram que a ré tem se dedicado à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

"A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas".

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que "essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder".

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de

vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)". (TJ/SP; Ap. 0003339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, chego à pena total e definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para cada réu.

O regime inicial do cumprimento de pena de ambos os acusados é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada, da quantidade de drogas e diante dos veementes indicativos de que a acusada está incisivamente inseridos na traficância.

Nesse sentido, inclusive, se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que diante das particularidades do caso concreto e da apreensão de grande quantidade de drogas é possível afastar a figura do tráfico privilegiado e fixar regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas.

2. A Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes", circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico.

3. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n.

11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juizes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que “diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.” Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão do “sursis”.

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Impossível a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos bens apreendidos, notadamente do imóvel em que a droga foi encontrada, salvo se restar evidenciado que pertence a terceira pessoa e que estivesse alugado.

Com efeito, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não garante que seja o real proprietário do bem, notadamente porque a propriedade de bem móvel se transfere com a mera tradição.

Ademais, o mero fato de o automóvel ter sido utilizado para a prática da empreitada criminosa é suficiente para que seja declarado perdido, não havendo, neste caso, que se arguir eventual direito de terceiro de boa-fé, pois ao se emprestar o bem a alguém, o proprietário (se se considerar que pertence a terceiro) está passível de perder o automóvel caso ele seja empregado em atividade ilícita.

Dessa forma, é evidente que o réu utilizava o bem para o fim específico de transportar entorpecentes.

Deveras, “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Concedo aos réus PABLO e IZABELLA o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Nego à ré ANA PAULA o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor, apenas se nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas “ex lege”.

P.I.C.

Itapeccerica da Serra, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA